EXCELENTÍSSIMO MINISTRO PRESIDENTE **DIAS TOFFOLI**, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS, entidade sindical de GRAU SUPERIOR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF nº 03.637.311/0001-54, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere, 5º andar, Grupo 502, Brasília – DF, CEP: 70070-915, por seus advogados que esta subscrevem, e pelo seu Presidente, **Miguel Eduardo Torres**, brasileiro, casado, metalúrgico, com fundamento **(a)** na Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 102, inc. I, alínea "a" e 103, inc. IX; e **(b)** na Lei n.º 9.868/1999, vem apresentar **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR** contra os arts. 477-A e 855-B, caput e § 2º, da CLT, incluídos pela Lei 13.467/2017 ("Reforma Trabalhista").

I. SÍNTESE DA AÇÃO: O ATO IMPUGNADO, A REPERCUSSÃO GERAL, O FUNDAMENTO E O PEDIDO:

Os atos impugnados são **(a)** o art. 477-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, quando assevera que não há *"necessidade de autorização prévia de entidade sindical"* para efetivação de *"dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas"*; e **(b)** o art. 855-B, caput e § 2º, da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, que retira a participação das entidades sindicais na homologação de acordos extrajudiciais.

> "Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)".

> "Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
>
> § 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)".

Tais atos impugnados, sabidamente, ao afastar os sindicatos das rescisões de contratos de trabalho e das homologações de acordos extrajudiciais, abalam, imensuravelmente, a tutela, proteção e regulação das relações de trabalho, um dos princípios vetoriais e basilares do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil.

A repercussão geral da controvérsia, como não poderia deixar de ser, é latente, diante de tudo o que foi dito acima. Vale dizer, o afastamento da presença sindical das rescisões de contratos de trabalho e das homologações de acordos extrajudiciais é fator que influencia e afeta, com veemência, a Economia, Política, Sociedade e Ordenamento Jurídico brasileiros.

Os atos impugnados afrontam a proteção que a Constituição Federal confere ao trabalho e ao meio ambiente do trabalho equilibrado, valores esses expressados pelos seguintes artigos do diploma constitucional: (a) art. 1º, IV; (b) art.6º; (c) art. 7º; (d) art. 170; (e) art. 193; (f) art. 203, III; e (g) art. 225, além de outros demonstrados nesta petição.

Mostra-se imperativa, portanto, a declaração da inconstitucionalidade das expressões:

(a) *"não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical* [...] *para sua efetivação"*, do art. 477-A da CLT;

(b) *"O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado"*, do art. 855-B, caput, da CLT, na medida em que torna obrigatória apenas a presença de advogados para homologação de acordo extrajudicial trabalhista, excluindo os sindicatos; e

(c) *"Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria"*, do art. 855-B, §2º, da CLT, uma vez que somente faculta ao trabalhador ser assistido por advogado da entidade sindical, e não algo obrigatório e de assistência da própria entidade sindical (não apenas seu advogado).

Assim, a presente ADI postula ao Pretório Excelso que:

(a) Cautelarmente, nos termos do art. 10 da Lei n.º 9.868/99, após a manifestação do Presidente da República e do Congresso Nacional, que deverão se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a eficácia das expressões elencadas no parágrafo anterior; e

(b) Definitivamente, após o regular processamento, declare a inconstitucionalidade, com efeitos *ex-tunc*, das expressões elencadas no parágrafo anterior; ou, caso assim não entenda,

(c) Que dê aos textos impugnados, acima transcritos, interpretação conforme a Constituição, para o fim de

assegurar a presença do sindicato profissional nas dispensas em massa e nas conciliações extrajudiciais.

II. SOBRE A LEGITIMIDADE DA AUTORA:

A legitimidade da autora decorre do disposto no art. 8º e 103, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999.

Com efeito, a autora é "Confederação Sindical" regularmente reconhecida pelo Decreto Presidencial nº 96.469, de 4/08/88, com prazo de duração indeterminado, com base territorial e jurisdicional em todo território nacional, consoante legislação em vigor, para fins de estudo, educação, instrução, coordenação, orientação, diversão, bem estar, lazer, administração, proteção, representação e defesa legal dos interesses difusos, coletivos e individuais dos integrantes da categoria profissional e representação legal das entidades sindicais e de trabalhadores inorganizados em sindicatos, nas INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E INFORMÁTICA, vinculadas ao 19º Grupo do Plano Nacional da Indústria (arts. 570 e 577 da CLT).

III. DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA:

Nos termos de seu Estatuto Social, a autora foi constituída para fins de estudo, educação, instrução, coordenação, orientação, diversão, bem-estar, lazer, administração, proteção, representação e defesa legal dos interesses difusos, coletivos e individuais dos integrantes da categoria profissional e representação legal das entidades sindicais e de trabalhadores inorganizados em sindicatos, nas INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E INFORMÁTICA.

Ademais, os atos impugnados visam o afastamento da presença sindical das rescisões de contratos de trabalho e das homologações de acordos extrajudiciais, afrontando a proteção que a Constituição Federal confere ao trabalho e ao meio ambiente do trabalho equilibrado.

Portanto, diante do fato de que os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, eletrônico e informática, em todo Brasil, **sob a tutela da autora**, perderam a proteção sindical nas rescisões de seus contratos de trabalho e homologações de acordos extrajudiciais, é cristalina a pertinência temática da autora em ajuizar a presente ADI.

IV. DO CONTEXTO DA PRESENTE AÇÃO: A REFORMA TRABALHISTA E A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR:

A Reforma Trabalhista veiculada pela Lei n.º 13.467, publicada em 13 de julho de 2017 e com *vacatio legis* de 120 (cento e vinte) dias da sua publicação, promoveu larga desregulamentação da proteção social do trabalho e inseriu 96 (noventa e seis) disposições na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a maior parte delas com redução de direitos materiais dos trabalhadores,[1] afastando e retirando atribuições dos sindicatos.

Os prejuízos sociais são enormes e se perfazem todos os dias, com empresas realizando transações individuais extrajudiciais, que, na prática, implicam em renúncia a direitos pelos trabalhadores e prejuízos no FGTS e INSS.

[1] A Lei 13.467/2017 facilita uso do trabalho autônomo (CLT, art. 442-B), amplia a contratação terceirizada de mão de obra (art. 2º), institui modalidades contratuais ultraflexíveis, como o trabalho intermitente (CLT, art. 452-A), fomenta negociação coletiva com finalidade redutora de direitos de fonte legal (CLT, arts. 611-A e 611-B), inclusive em matérias relativas a saúde e segurança do trabalhador (CLT, art. 611-A, XII), flexibiliza a composição salarial (CLT, art. 457, §§ 2º e 4º) e a jornada de trabalho (CLT, arts. 59, §§ 5º e 6º, 59-A, 59-B, 611-A, I a III, e 611-B, parágrafo único), dificulta a equiparação salarial (CLT, art. 461, §§ 1º e 5º), entre outras medidas redutoras de garantias materiais dos trabalhadores.

Por isso, é urgente que se conceda medida cautelar para suspender a eficácia dos atos impugnados, dado que sua aplicação acarretará prejuízos irreparáveis às relações trabalhistas.

V. DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS *EX-TUNC*:

A Lei nº 13.467/2017 alterou a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, com a suposta finalidade de adequar a legislação às novas relações de trabalho, no que, porém, foi inconstitucional.

Nesse contexto, a Reforma Trabalhista colocou em vigor os atos impugnados elencados anteriormente, os quais são flagrantemente inconstitucionais, haja vista promoverem um retrocesso imensurável nos direitos sociais consagrados pela Ordem Jurídica e Democrática Brasileira que são afetos aos direitos trabalhistas.

A esse respeito, a saúde, a vida, a segurança, a dignidade da pessoa humana, valores sociais dos trabalhos, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais, o primado do trabalho, o bem-estar, a justiça social e o meio ambiente de trabalho equilibrado são direitos fundamentais constitucionais que correm risco de extinção ou, no mínimo, vasta diminuição com a edição e efeitos dos atos impugnados.

VI. JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E CONSIDERAÇÕES LEGISLATIVAS ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS:

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal se manifestou expressamente no sentido de que o ato impugnado art. 477-A da

CLT é inconstitucional, na medida em que retira do trabalhador a proteção contra dispensa coletiva, representando flagrante retrocesso (https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5371361&disposition=inline).

A 2ª Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho, em sua Comissão 5, por meio do Enunciado 1, conduzida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, assentou a tese de que o aludido art. 477-A é inconstitucional. Confira-se:

> "DISPENSA COLETIVA: INCONSTITUCIONALIDADE
>
> Ementa: O ART. 477-A DA CLT PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE, ALÉM DE INCONVENCIONALIDADE, POIS VIOLA OS ARTIGOS 1º, III, IV, 6º, 7º, I, XXVI, 8º, III, VI, 170, CAPUT, III E VIII, 193, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO TAMBÉM O ARTIGO 4º DA CONVENÇÃO Nº 98, O ARTIGO 5º DA CONVENÇÃO Nº 154 E O ART. 13 DA CONVENÇÃO Nº 158, TODAS DA OIT. VIOLA, AINDA, A VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE E DE RETROCESSO SOCIAL. AS QUESTÕES RELATIVAS À DISPENSA COLETIVA DEVERÃO OBSERVAR: A) O DIREITO DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL; B) O DEVER GERAL DE BOA FÉ OBJETIVA; E C) O DEVER DE BUSCA DE MEIOS ALTERNATIVOS ÀS DEMISSÕES EM MASSA." (http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=5).

A jurisprudência do TST, igualmente, é no sentido de que a dispensa em massa de trabalhadores caracteriza abuso de direito se não autorizada previamente pelo sindicato da categoria correspondente. Nesse sentido, confira-se o RO-6155-89.2014.5.15.0000 (RO-6155-89.2014.5.15.0000). O acórdão paradigmático, que se encontra no âmbito desta Excelsa Suprema Corte, em grau de Recurso Extraordinário, é o Proc. TST 309/2009-000-15-00.4, sobre a EMBRAER, cuja ementa segue abaixo:

> **RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. DISPENSAS TRABALHISTAS COLETIVAS. MATÉRIA DE DIREITO COLETIVO. IMPERATIVA INTERVENIÊNCIA SINDICAL. RESTRIÇÕES JURÍDICAS ÀS DISPENSAS COLETIVAS. ORDEM CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA EXISTENTE DESDE 1988.** A sociedade produzida pelo sistema capitalista é,

essencialmente, uma sociedade de massas. A lógica de funcionamento do sistema econômico-social induz a concentração e centralização não apenas de riquezas, mas também de comunidades, dinâmicas socioeconômicas e de problemas destas resultantes. A massificação das dinâmicas e dos problemas das pessoas e grupos sociais nas comunidades humanas, hoje, impacta de modo frontal a estrutura e o funcionamento operacional do próprio Direito. Parte significativa dos danos mais relevantes na presente sociedade e das correspondentes pretensões jurídicas têm natureza massiva. O caráter massivo de tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar, deslocando-se da matriz individualista de enfoque, compreensão e enfrentamento dos problemas a que tradicionalmente perfilou-se. A construção de uma matriz jurídica adequada à massividade dos danos e pretensões característicos de uma sociedade contemporânea – sem prejuízo da preservação da matriz individualista, apta a tratar os danos e pretensões de natureza estritamente atomizada – é, talvez, o desafio mais moderno proposto ao universo jurídico, e é sob esse aspecto que a questão aqui proposta será analisada. As dispensas coletivas realizadas de maneira maciça e avassaladora, somente seriam juridicamente possíveis em um campo normativo hiperindividualista, sem qualquer regulamentação social, instigador da existência de mercado hobbesiano na vida econômica, inclusive entre empresas e trabalhadores, tal como, por exemplo, respaldado por Carta Constitucional como a de 1891, já há mais um século superada no país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, por conseqüência, direitos trabalhistas, e em face da leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é inevitável concluir-se pela presença de um Estado Democrático de Direito no Brasil, de um regime de império da norma jurídica (e não do poder incontrastável privado), de uma sociedade civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à dignidade dos seres humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de pessoas, abalando empresa, cidade e toda uma importante região. Em conseqüência, fica fixada, por interpretação da ordem jurídica, a premissa de que "a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores". **DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS.** A ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios constitucionais que determinam

> o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego (arts. 1º, IV, 6º e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua função socioambiental (arts. 5º, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8º, III e VI, CF), tudo impõe que se reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, *para casos futuros*, de que "a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores", observados os fundamentos supra. **Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.**
>
> **(TST/SDC, RO 309/2009-000-15-00.4 [RO 0030900-12.2009.15.0000], Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, j. 10.08.2009).**

Dita decisão se encontra sob exame de Recurso Extraordinário (ARE 647651, reautuado para RE 999435, Rel. Min. Marco Aurelio, Repercussão Geral reconhecida), encontrando-se o Ministério Público do Trabalho a defender a tese favorável à intervenção dos sindicatos nas demissões em massa, o que encontra eco em Parecer da PGR, a cujas razões ora se acosta, na esteira do item VII (v. adiante), de logo pedindo vênias para acompanhá-las integralmente.

O TRT-4, na mesma linha, já teve a oportunidade de declarar a inconstitucionalidade, de maneira expressa, do art. 477-A da CLT (https://www.trt4.jus.br/portais/media-noticia/156708/uniritter.pdf).

IGOR DE OLIVEIRA ZWICKER, em seu artigo *"A Dupla Incompatibilidade Vertical Material do art. 477-A da Consolidação das Leis do Trabalho"*, de maneira brilhante, também assevera a flagrante inconstitucionalidade do aludido ato impugnado (http://www.ltr.com.br/congressos/jornal/direito/jornal_direito.pdf).

VII. DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NAS DEMISSÕES EM MASSA:

Tem-se em liça o importante tema da eficácia de direitos sociais, constitucionalmente assegurados e vinculados à justiça social, em face da liberdade econômica. Os direitos trabalhistas, dentre os quais se destaca o direito ao emprego e de reabsorção do trabalhador no mercado de trabalho, constituem indiscutível capítulo da Constituição Federal, cabendo ao intérprete assegurá-los. Como direitos de segunda dimensão, a participação do Estado é imprescindível para sua garantia e implementação. Ao contrário dos direitos de primeira dimensão (as chamadas *"liberdades públicas",* insculpidas na pauta dos *"direitos e garantias individuais"*), a violação dos **direitos sociais** facilmente se concretiza com a simples **omissão** do Estado, não só na via jurídica, mas também política e econômica, considerando a complexidade dos instrumentos necessários a assegurar referidos direitos. Neste sentido é que se compreende a lição de J. J. Canotilho e Vital Moreira, ao comentarem o sistema constitucional português, idêntico ao brasileiro neste ponto, *litteris:*

> "Para além destes efeitos jurídicos directos, os direitos sociais têm ainda uma relevância jurídico-constitucional indirecta. Assim: *(a)* sendo eles direitos constitucionalmente protegidos, pode a sua realização justificar a limitação do exercício de outros direitos constitucionais, nos casos constitucionalmente previstos (cfr. Art. 18º-2); *(b)* tendo a natureza de 'direitos econômicos, sociais e culturais' e consistindo em direitos a acções ou prestações públicas, eles justificam e exigem do Estado a necessária intervenção no campo económico, social e cultural (sem prejuízo, quanto ao campo cultural, do princípio da não programação cultural do art. 43º-2), designadamente pela transformação das estruturas económicas e sociais (art. 9º/d); *(c)* dependendo a realização de muitos deles da disponibilidade de recursos económicos e financeiros e sendo certo que esta é condicionada, não apenas pelo seu nível absoluto, mas também pela repartição social da riqueza e dos rendimentos, então os direitos impõem a acção do Estado contra a desigualdade económica (arts. 9º/d e 81º/b)."[2]

A liberdade econômica, mesmo sendo direito inerente à atividade empresarial, não é absoluta, porque há limites sociais, estabelecidos constitucionalmente. Aliás, nenhum direito fundamental é absoluto, porquanto seus limites esbarram na satisfação de outros direitos fundamentais e do próprio interesse público,

[2] CANOTILHO, J.J. Gomes & MOREIRA, Vital. *Fundamentos da Constituição.* Coimbra: Coimbra Editora, 1991, p. 131-132.

para que possam conviver harmonicamente. Ao comentarem a Constituição Portuguesa vigente, Canotilho e Vital Moreira lecionam:

> "A liberdade de iniciativa económica privada encontra-se explicitamente condicionada em função do **interesse geral** (nº 1), o que sublinha a sua 'funcionalidade' constitucional. Trata-se de um típico *conceito constitucional indeterminado,* destinado a funcionar como fator de legitimação constitucional da intervenção legislativa na liberdade de iniciativa (para efeitos do art. 18º-2, in fine), cuja 'densificação' deve arrancar, em primeiro lugar, das determinantes heterônomas fornecidas pela própria lei fundamental, sendo de destacar, de entre várias, as seguintes: aumento do bem-estar e da qualidade de vida do provo (arts. 9º/b, 64º-3/d e 81º/*a* e *b*); realização dos direitos dos trabalhadores, a começar pelo direito ao trabalho (art. 58º); subordinação do poder económico ao poder político (art. 80º/b); aumento da produção e plena utilização das forças produtivas (arts. 81º/a e c e 88º); defesa da independência nacional (arts. 9º/a e d, 81º/g e 87º); crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões (art. 82º/d); defesa do ambiente e utilização racional dos recursos naturais (arts. 66º e 93º-1/d).
>
> De um outro ponto de vista, o compromisso constitucional da iniciativa privada com o interesse geral, embora não seja susceptível, de só por si, estabelecer deveres ou obrigações das empresas para com a colectividade, legitima seguramente a noção de 'responsabilidade social' das empresas, consubstanciada em iniciativas em prol dos seus trabalhadores (obras sociais) e da colectividade em geral (apoio a escolas, museus, realizações culturais)."[3]

No caso específico do Brasil, a Constituição pátria estabelece claramente a delimitação dos direitos inerentes à atividade econômica, valendo destacar o caráter humanitário da exploração empresarial, o cumprimento da sua função social das empresas, a dignidade do trabalho humano e o respeito ao consumidor.

Infringe aos propósitos da Constituição a dispensa de grande número de trabalhadores, simultaneamente, pelo exercício de uma faculdade empresarial, sem nenhuma preocupação com os reflexos sociais daí gerados.

VII. (a). DISPENSA COLETIVA: ADMITIDA, RECHAÇADA OU CONDICIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL?

A princípio, antes de qualquer outro enfrentamento, há que se indagar se, no Direito pátrio, capitaneado pela Constituição Federal, a dispensa coletiva

[3] CANOTILHO, J.J.Gomes & MOREIRA, Vital. *CRP-Constituição da República Portuguesa:* Anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Editora, 2007, comentários ao art. 61º, p. 791-792.

é distinguida como um fenômeno próprio, um fato social único, com seus particulares fundamentos, causas, condições e consequências; ou se, na despedida em massa, tem-se apenas um conjunto de dispensas individuais, num claro exercício, por parte do empregador, de seu direito potestativo de despedir. Os efeitos da adoção de uma ou outra tese são enormes para trabalhadores e empresários no Brasil.

Orlando Gomes entendia, já nos idos da década de 1970, que os efeitos da dispensa coletiva não devem ser os mesmos da individual, sem justa causa ou por força maior. Asseverava, por exemplo, que tem cabimento a dilação do aviso prévio normal, variável em função da antiguidade do trabalhador na empresa. Nessa linha, sustentava o renomado autor que dispensa coletiva é a rescisão simultânea, por motivo único, de uma pluralidade de contratos de trabalho numa empresa, sem substituição dos empregados dispensados. Dois traços caracterizariam a dispensa coletiva, a *peculiaridade da causa* e a *redução definitiva do quadro de pessoal*.[4]

A diferença entre dispensa individual e coletiva foi ressaltada também pelo renomado Doutor e Professor da PUC-SP, **Renato Rua de Almeida**, que, examinando as características gerais do regime da proteção da relação de emprego contra a despedida individual sem justa causa no Direito do Trabalho contemporâneo, de passagem, faz distinção da despedida individual e coletiva: A despedida individual justifica-se por fato de natureza disciplinar (justa causa) imputável ao empregado ou por inaptidão profissional às mudanças técnicas da empresa. Já a despedida coletiva é arbitrária ou não, dependendo da existência comprovada de fato objetivo relacionado à empresa, causado por motivo de ordem econômico-conjuntural ou técnico-estrutural. [5]

Como fatos sociais, parece **indubitável** a **distinção** entre a dispensa individual e a dispensa coletiva. Enquanto aquela geralmente tem motivação ligada à pessoa do trabalhador, esta tem razões ligadas à empresa, para as quais os empregados não concorreram. Tomando a medida de dispensar uma pluralidade de empregados não visa o empregador a pessoas concretas, como na despedida individual,

[4] GOMES, ORLANDO. Dispensa Coletiva na Reestruturação da Empresa – Aspectos Jurídicos do Desemprego Tecnológico, in *Revista LTr*, ano 38, São Paulo, Julho de 1974.
[5] ALMEIDA, Renato Rua. O regime geral do direito do trabalho contemporâneo sobre a proteção da relação de emprego contra a despedida individual sem justa causa: estudo comparado entre a legislação brasileira e as legislações portuguesa, espanhola e francesa. *Revista LTR*, São Paulo, v. 71, n. 03, p. 336 - 345, mar. 2007.

mas a um grupo de trabalhadores identificáveis apenas por traços pessoais, como a lotação em certa seção ou departamento da empresa, a qualificação profissional ou o tempo de serviço.[6]

Se um empregador, sem qualquer motivo relevante ou plausível, deseja arbitrariamente encerrar o contrato de trabalho de um de seus trabalhadores, configura-se aí um **conflito entre dois interesses individuais**: o do empregador de despedir o seu funcionário e o do empregado de permanecer no emprego, sem repercussão social considerável imediata. Neste caso, previu a Constituição Federal, em seu art. 7º, I, proteção à relação de emprego, a ser efetivada por meio de Lei Complementar; como a mencionada proteção ainda não foi regulamentada pelo Congresso Nacional, continua vigente o art. 10 do ADCT, segundo o qual, como forma de inibição da conduta e, ao mesmo tempo, de reparo ao trabalhador, deve o patrão indenizar seu funcionário em multa equivalente a 40% dos depósitos realizados ao FGTS, inteligência corroborada pela Lei nº 8.036/90 (Lei do FGTS). Indiscutível, portanto, o direito potestativo do empregador de despedir seu empregado, pois a necessidade de pagamento de indenização não significa empecilho à terminação do contrato, senão mera consequência jurídica de quem lhe deu causa.

Dessa forma, diante do conflito entre dois interesses individuais (do empregador e do empregado), optou o Ordenamento Jurídico vigente por proteger o interesse do trabalhador, mas dar prevalência à vontade empresarial, condicionando-a apenas à indenização acima mencionada, desde que, é claro, não haja qualquer motivação de caráter discriminatório. Este foi o sopesamento feito pelo constituinte de 1988, que admitiu alguns casos excepcionais de estabilidade provisória.

No caso da despedida arbitrária coletiva, porém, a linha de raciocínio deve ser completamente distinta. Isso porque não se trata mais de conflito entre interesses individuais, mas de conflito entre a vontade do empregador (individual) e o interesse não só da coletividade de funcionários (coletivo), mas de toda a sociedade (público). Em última análise, **contrapõe-se a vontade privada e o interesse público**. Isso ocorre porque, além das consequências particulares da perda do emprego para cada trabalhador, a despedida de vários empregados tem enorme repercussão social, na

[6] GOMES, ORLANDO. *Op Cit.*

medida em que onera a seguridade social, leva à utilização maciça do seguro-desemprego, ao saque coletivo do FGTS e prejudica toda a sociedade, que passará a conviver com as inúmeras repercussões negativas do aumento do desemprego.

Consoante destacado no acórdão proferido pelo TST, de relatoria do Ministro **Maurício Godinho Delgado**, a dispensa coletiva é fato distinto da dispensa individual em sua estrutura, dimensão, profundidade, efeitos, impactos e repercussões. Corresponde a fato econômico, social e jurídico diverso da despedida individual, pela acentuação da lesão provocada e pelo alargamento de seus efeitos, que deixam de ser restritos a alguns trabalhadores e suas famílias, atingido, além das pessoas envolvidas, toda a comunidade empresarial, trabalhista, citadina e até mesmo regional, abalando, ainda, o mercado econômico interno.

A dispensa coletiva acarreta **impacto social** tamanho, que afasta a perspectiva meramente individual, aproximando-a do interesse público. Afinal, as consequências sociais serão nítidas, a impactar as finanças do Estado (seguro desemprego, saque do FGTS...) e afetar sensivelmente um setor profissional ou econômico, considerando o desemprego de centenas de trabalhadores da mesma categoria. Quando, por exemplo, poucas empresas exploram determinada atividade econômica de relevância, como o setor de aviação, a dispensa em massa afeta profundamente o setor, até em termos de percentual da categoria, podendo alcançar 5%, 10% ou mais da mão-de-obra utilizada. E isso ofende o propósito idealístico da busca do pleno emprego, primado consagrado pela Constituição Federal (art. 170).

Nesse caso, portanto, é fundamental que prevaleça o interesse da coletividade dos trabalhadores, fazendo valer a **supremacia do interesse público** sobre o privado, o social sobre o exclusivamente empresarial. Na lição de Paulo Ricardo Schier, o princípio da supremacia do interesse público ingressa no ordenamento jurídico brasileiro pelo espírito de imposição de uma superioridade *a priori*, não para fins de realização das razões de Estado, mas para o exercício de uma desigualdade frente aos interesses particulares, apenas para a imposição e satisfação dos direitos e garantias fundamentais, inseridos na atual ordem constitucional, como legítimos interesses públicos.

"[...] O Estado legitima-se e justifica-se a partir dos direitos fundamentais e não estes a partir daquele. O Estado gira em torno do núcleo gravitacional dos direitos fundamentais".[7]

Nesse contexto, configura abuso de direito e violação ao princípio da supremacia do interesse público a despedida arbitrária de uma coletividade de trabalhadores. Mostra-se absurdo suprimir toda uma coletividade em nome unicamente da vontade empresarial.

Embora não exista norma expressa que detalhe todos os pressupostos e consequências de uma dispensa coletiva, o texto constitucional é **repleto de indícios** que apontam de forma irrefutável para a sua **vedação quando imotivada**, diferentemente do disciplinado com relação à despedida individual, o que evidencia, manifestamente, o caráter social escolhido pelo constituinte para permear o Estado Brasileiro. O lema segundo o qual *tudo quanto não é proibido é permitido,* muito apropriado ao regime de liberdades e aos direitos fundamentais de primeira dimensão (naturalmente individuais), recebe ponderações nos Estados sociais, com matizes muito mais adequados aos direitos sociais, culturais e econômicos. As dispensas coletivas são realidades indissociáveis dos interesses sociais. E, assim, merecem um olhar mais crítico do hermeneuta. É esta a orientação que a Constituição Federal confere ao aplicador da norma.

O ponto de partida são os fundamentos do Estado Democrático de Direito. De acordo com o **art. 1º** da CF/88, o Brasil se alicerça na soberania, na cidadania, na **dignidade da pessoa humana**, nos **valores sociais do trabalho** e da livre iniciativa e no pluralismo político. Nesse contexto, não se apresenta razoável admitir que a mesma nação que tem como fundamento maior a dignidade da pessoa humana e se alicerça nos valores sociais do trabalho reconheça que uma empresa possa, discricionariamente, sem qualquer fundamento, despedir milhares de trabalhadores, provocando sérios prejuízos aos indivíduos que dependem daquele emprego, aos seus familiares e a toda a sociedade em que estão inseridos.

[7] SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. In: SARMENTO, Daniel (Org.). *Interesses públicos versus interesses privados:* desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 217-246.

Prosseguindo na análise constitucional, o **art. 3º** da Carta Política determina como objetivos fundamentais da República brasileira: construir uma sociedade livre justa e **solidária**; garantir o **desenvolvimento nacional**; erradicar a **pobreza** e a **marginalização** e **reduzir as desigualdades** sociais e regionais; promover o **bem de todos**, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos são propósitos a serem alcançados. Como finalidades, constituem um projeto nacional a ser logrado gradativamente, em processo continuado e dirigido pelo Poder Público, o grande dirigente dos rumos da Nação. Se fosse admitida a despedida coletiva, nos moldes da individual, a nação brasileira estaria caminhando para um destino exatamente inverso daquele pretendido pela Carta Política, em situação de evidente auto sabotagem. Ou seja, entender que a Constituição acolhe a dispensa em massa, prevendo a ela tratamento idêntico à individual, é coadunar-se com uma irreparável contradição dentro do próprio texto constitucional, uma vez que isso iria de encontro a uma sociedade justa e solidária, ao passo que inviabilizaria o desenvolvimento social e colaboraria com a pobreza, com a marginalização e com as desigualdades sociais, pelo que, por certo, não se promoveria o bem de todos.

O **art. 170** da Constituição, por sua vez, é o primeiro a tratar da Ordem Econômica e Financeira, expressando, logo em seu *caput*, que a ordem econômica é fundada na **valorização do trabalho humano**, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames **da justiça social**; mais adiante, estatui como princípio a função social da propriedade e a **busca do pleno emprego**. Esse dispositivo revela muito acerca do Estado Brasileiro, que tem como modo de produção o capitalismo, mas se ergue sob bases fortemente sociais. O trabalho humano deve sempre, portanto, ser valorizado, sendo a busca do pleno emprego mais um dos objetivos do Estado Brasileiro. Por mero esforço intelectivo, resta óbvio que tais primados não se compatibilizam com o acatamento, sem qualquer limitação, da dispensa de milhares de trabalhadores, em manifesta expressão do mais absoluto e irrestrito individualismo, prejudicando toda a sociedade em nome do interesse privado.

A **justiça social**, consagrada também no art. 170 da Constituição, é outro conceito de suma importância para que se entenda o Estado Brasileiro, contribuindo para a conclusão de que este rechaçou, sem qualquer hesitação,

a dispensa coletiva nos moldes da individual. A justiça social é um meio de se alcançar o progresso social, que é pressuposto do desenvolvimento.[8] O intérprete, segundo os ditames da justiça social, não pode aplicar a norma de maneira isolada, dogmática, sem levar em consideração a sociedade em que está inserido e as consequências da sua interpretação; não pode valer-se apenas do comando expressamente determinado, ignorando os conceitos abstratos, indeterminados e os princípios constitucionais. O intérprete não pode, enfim, se desviar das bases que formam o constitucionalismo do país.

Ruprecht esclarece que a consequência da justiça social é a introdução de uma orientação aos conceitos dominantes, quer dizer, "a justiça comutativa, que estabelece uma igualdade absoluta; a distributiva, de acordo com a capacidade econômica de cada um; e a legal, que rege as relações individuais com a sociedade. A justiça social tende a elevar o nível de vida dos trabalhadores".[9]

Sob mais esse prisma, interpretar a dispensa coletiva como sendo um conjunto de despedidas individuais, violaria frontalmente a justiça social, ante o profundo abalo que causaria em toda a sociedade, não sendo, em última análise, uma decisão socialmente justa e, portanto, não se coaduna com o espírito da Constituição. A conclusão é a de que não é esse o comando do texto maior nem foi essa a intenção do constituinte.

Mais adiante, na Carta Constitucional, em seu **art. 193**, o único dispositivo de todo um título (Título VIII – Da Ordem Social), estatui-se que a **ordem social** tem como base o **primado do trabalho**, e como **objetivo** o **bem estar** e a **justiça sociais**. Aqui importa elucidar o que seja ordem e o que caracteriza uma ordem social.

Ordem é um conceito que advém da matemática, exprimindo uma particular relação entre objetos distintos segundo um determinado critério organizador. Assim, números naturais, dispostos em sequência do menor para o maior, formam uma ordem, na medida em que existe um critério organizador. Quando se deixa o campo das ciências exatas para as ciências humanas, no qual a ordem não é

[8] MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. *Os Princípios de Direito do Trabalho na Lei e na Jurisprudência*. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1997, p. 23.
[9] RUPRECHT, Alfredo J. *Os Princípios do Direito do Trabalho*. São Paulo: LTr, 1995, p. 108.

propriamente criada, mas descoberta pelo pesquisador, abre-se a possibilidade de ordens artificiais, ordens que não são dadas pela natureza, mas que são instauradas por intervenção humana. Neste caso, há a possibilidade de que os mesmos entes sejam arranjados de múltiplas maneiras: a ordem dos números inteiros é uma só, mas a ordem dos livros numa estante pode se basear no assunto da obra, no seu autor ou na data de sua publicação. O que vai definir qual das possíveis ordens será instaurada é justamente a **finalidade** buscada com a sua instauração.

A **ordem social**, contudo, diferencia-se de qualquer outra ordenação, na medida em que organiza não objetos, ou mesmo indivíduos, mas **comportamentos humanos**, que são sempre imprevisíveis. É por isso que não é possível, na busca pela ordem social, determinar como se comportará cada indivíduo, sendo viável apenas estabelecer como deve ser o seu comportamento, nascendo daí o sentido da norma jurídica como um dever-ser.

A norma jurídica deverá, portanto, estabelecer como deverá ser o comportamento humano, de acordo com dada finalidade estabelecida pelo próprio Estado. Essa **finalidade** é o que realmente interessa no presente estudo. No caso brasileiro, a ordem social, como mencionado no art. 193 da CF, tem por **primado o trabalho** e como objetivos o **bem estar** e a **justiça social**.

Isso quer dizer que todas as **normas** e todas as condutas humanas **devem voltar-se** à **proteção do trabalho**, com a finalidade última de garantir o **bem estar da sociedade** e assegurar a **justiça social**, conceito já abordado nesta análise. Esse é mais do que um indício, é uma demonstração de que o Estado Brasileiro, na forma estatuída pela Constituição Federal, não pode se coadunar com uma dispensa coletiva na mesma conformação de uma despedida individual, o que desarticularia a ordem social, desagregando a própria sociedade.

Na verdade, se a Constituição não estabeleceu expressa e literalmente o tratamento privilegiado nas **dispensas coletivas**, também não possui nenhum dispositivo manifesto sobre a **denúncia vazia** ou o **direito potestativo** no campo das relações de trabalho. O direito potestativo de rescisão é extraído da análise sistêmica da Constituição, corroborado pelos princípios do Direito do Trabalho. Da mesma forma, e por uma igualdade reclamada ao hermeneuta, o tratamento social a ser requerido

há seguir a mesma linha assecuratória, porquanto respaldada em dispositivos constitucionais e em primados inerentes aos direitos sociais/coletivos. Por amor ao debate, levanta-se que o reconhecimento do direito potestativo de rescisão não se encontra encravado nas letras da Constituição como direito fundamental das empresas, mas, mesmo que assim se entenda, registra-se que os direitos fundamentais não são absolutos, porquanto eles se comunicam no texto constitucional, a exigir a observância da **unidade da Constituição**.

Diante de todo o exposto, conclusão outra não há, senão a de que a Constituição Federal estabeleceu tratamento completamente diferenciado à dispensa coletiva, quando comparada à individual. Não pode o empregador despedir milhares de trabalhadores, mediante unicamente o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS; nesse caso, reclama a Constituição uma proteção maior, por envolver, não apenas interesses individuais, mas coletivos e públicos.

Prima Face, como exaustivamente demonstrado, tem-se como vedada, pela Carta magna, a dispensa arbitrária de coletividade de trabalhadores. Impossibilitar, contudo, peremptoriamente essa espécie de despedida seria ignorar a realidade capitalista e talvez criar um bloqueio ao desenvolvimento econômico, causando prejuízo a um numero ainda maior de trabalhadores, uma vez que é possível que a empresa passe por crise econômica tão severa que, se não despedir certa quantidade de empregados, caminhará invariavelmente para a falência.

Alcançada a conclusão de que a dispensa coletiva merece tratamento diferenciado, estando vedada quando realizada de forma arbitrária, contudo, considerando que **não se pode impossibilitar, por completo, esta forma de despedida**, exsurge a seguinte indagação: quais seriam as limitações para a dispensa coletiva? E quais seriam os requisitos para que ela seja operada?

Quanto às limitações, dado que é vedada pela Constituição Federal a despedida coletiva de forma arbitrária, conclui-se que é imprescindível a **demonstração de dificuldade** de caráter econômico-conjuntural, técnico-estrutural ou uma crise econômica internacional, de forma que se torne imperiosa a despedida sob pena de afetar o próprio funcionamento da companhia. Esta realidade precisa ser apresentada e discutida com o sindicato, o qual, após realizar assembleia com os trabalhadores, poderá

preferir a redução salarial dos demais, provisoriamente, *ex vi* do art. 7º, VI, CF, que permite o chamado *acordo japonês,* ao invés da dispensa coletiva.

Não obstante, mesmo depois de verificada a autenticidade do elemento objetivo motivador da dispensa coletiva, não estará o empregador autorizado a despedir, discricionariamente, quantos e quais trabalhadores entenda mais vantajoso ou apropriado, nem se apresenta razoável a aplicação como elemento reparador apenas da multa de 40% sobre o montante do FGTS. Isso ocorre em virtude de toda a lógica constitucional já delineada no presente estudo, devendo-se **proteger, ao máximo, a coletividade** de trabalhadores. Assim, sendo a dispensa coletiva imprescindível para a sobrevivência da empresa, ela terá de ser, invariavelmente, realizada, ocasião em que deve o empregador primar pela **ponderação**, como forma de **compatibilizar e harmonizar os interesses**, causando um **prejuízo atenuado** aos próprios trabalhadores e à própria sociedade.

Portanto, se a empresa tem real necessidade de "enxugar" o quadro de pessoal por motivos econômicos ou financeiros, não faz sentido que o processo de dispensa comece pelo desligamento de estáveis ou portadores de garantias especiais no emprego, por exemplo; nem pelos veteranos. Esta inteligência, há muito consagrada pela doutrina e pela jurisprudência trabalhistas, acabou sendo alçada à Constituição Federal para se aplicar aos servidores públicos quando a Administração necessitar reduzir despesas com pessoal para atender aos limites estabelecidos pela lei orçamentária (art. 169, caput e § 3º, CF).

Além dos **estáveis**, deve-se proteger, ainda, **aqueles portadores de deficiência física ou mental**, bem como os mais **idosos**, uma vez que a obtenção de novo emprego, nesses casos, torna-se tarefa claramente mais árdua. Há de se ver que há limitações estabelecidas em certas Convenções ou Acordos Coletivos, como a estabilidade pré-aposentadoria.

Em síntese, o empregador, no processo de escolha daqueles que terão de deixar o emprego, deve observar a condição do empregado na empresa, bem como a possibilidade que esse funcionário tem de obter uma nova função produtiva na sociedade; deve preocupar-se, portanto, com as **consequências externas** da despedida coletiva, e não apenas com os benefícios que ela trará à sobrevivência da

companhia. A **livre iniciativa** deve, portanto, ser **exercida de acordo com ditames da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da função social da propriedade**, nela incluída a função social dos meios de produção ou da empresa. É o que se extrai do texto constitucional.

Nesse mesmo sentido já decidiu o **Superior Tribunal de Justiça**, em acórdão nos autos do Mandado de segurança 3351-4/DF, de relatoria do Ministro Demócrito Reinaldo, na primeira seção, publicado em 10/08/1994, *in verbis*:

> *No domínio do desenvolvimento – conjunto de bens e riquezas a serviço de atividades lucrativas – **a liberdade de iniciativa constitucionalmente assegurada, fica jungida ao interesse do desenvolvimento econômico nacional da justiça social** e se realiza visando à harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção, admitindo a Lei Maior que a União intervenha na esfera da economia para suprimir ou controlar o abuso do poder econômico.*

Os primados constitucionais de proteção do trabalhador deverão estar presentes também no momento de estabelecer a **forma de reparação dos empregados** dispensados. O objetivo aqui também é **atenuar os efeitos da despedida coletiva**, fazendo com que a sociedade não os sinta de forma tão intensa. Deve-se preparar o trabalhador para a dispensa e indenizá-lo de forma suficiente para que mantenha o seu sustento e o de sua família até que obtenha novo emprego.

Todavia, **não é possível ao intérprete do direito** estabelecer exatamente quais os **patamares indenizatórios mínimos** que devem ser garantidos em uma dispensa coletiva, nem fixar todos os critérios para a escolha daqueles que, infelizmente, perderão seus postos de trabalho. E é melhor que assim o seja; **cada situação demanda uma solução única e específica**; é preciso analisar a quantidade de trabalhadores a serem despedidos, o tamanho e a capacidade econômica da empresa, bem como a magnitude da crise pela qual se atravessa, além de critérios particulares de cada situação.

Seria prejudicial tanto ao trabalhador, quanto à empresa e, em última análise, à própria sociedade que o legislador ou o intérprete fixasse tais patamares ou tais condições para a dispensa coletiva, tendo em vista que, por certo,

haveria situações em que eles não seriam suficientes, seja para garantir o menor impacto social, seja para assegurar a recuperação da empresa.

Conclui-se, portanto, que é **necessária a análise particular** de cada caso concreto para se determinar o que seja suficiente e razoável, num processo de **ponderação**, para se garantir o menor impacto e, ao mesmo tempo, a recuperação da companhia. Tendo em vista que não cabe ao Judiciário imbuir-se desse mister, haja vista que isso apenas colaboraria com o conflito e não se alcançaria a solução mais adequada, resta aos **sujeitos coletivos** a discussão e o consenso do que seja o equilíbrio em cada caso. A Constituição Federal, novamente, se coaduna e indica que essa é, de fato, a **solução socialmente adequada**.

O **art. 8º da CF** estabelece o primado da liberdade sindical, delineando de que forma se dará a atuação das associações sindicais no país. Para o presente estudo, é crucial destacar os incisos **III e VI** desse dispositivo constitucional.

> III – ao **sindicato** cabe a **defesa dos direitos e interesses coletivos** ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
>
> VI – é **obrigatória a participação** dos **sindicatos** nas **negociações** coletivas de trabalho

Dos dois incisos supratranscritos denota-se **o papel central e indispensável das entidades sindicais** no que se refere ao interesse de uma coletividade de trabalhadores. A defesa desses direitos coletivos impõe-se não à Administração Pública ou ao Judiciário, mas unicamente aos sindicatos, organizações constitucionalmente autorizadas a defender os interesses dos trabalhadores.

Sendo a dispensa coletiva matéria que orbita em torno de **interesses coletivos**, consoante exaustivamente enfatizado, demandando a defesa de direitos também coletivos, indubitável que tal amparo terá de ser alcançado por meio da atuação das entidades sindicais, de acordo com o que preceitua o **art. 8º, III da CF/88**.

Ademais, uma vez que a **negociação** entre os sujeitos envolvidos na despedida coletiva se apresenta como a única solução social e constitucionalmente adequada, imperiosa a conclusão de que se faz imprescindível a

participação dos sindicatos nesse *mister*, conforme o mandamento do **art. 8º, VI da CF/88**.

Para que haja uma despedida de caráter coletivo é indispensável, portanto, que haja real e relevante motivo para tanto e que seja imprescindível a dispensa. Nessa situação, é necessário, ainda, que se encontre um equilíbrio entre as necessidades das empresas e as dos trabalhadores, atenuando o impacto social da dispensa, em nome do interesse público e da função social da propriedade. A única forma de se atingir um equilíbrio verdadeiro e eficaz é por meio do **diálogo entre os próprios agentes envolvidos**, ou seja, empregador e trabalhadores, sendo esses representados pelo sindicato da categoria, em homenagem ao art. 8º, III e VI da CF/88. Por fim, conclui-se que a Constituição determina, como condição de validade da dispensa em massa, prévia negociação coletiva.

Em suma: não é razoável que as dispensas coletivas recebam o mesmo tratamento das dispensas individuais, haja vista que o impacto que ocasionam à sociedade e a lesividade aos cofres públicos são distintos.

VII. (b) A NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL

O direito internacional, consubstanciado nas convenções internacionais incorporadas ao direito brasileiro, também deixa claro que a despedida coletiva deve ser entendida de maneira distinta da individual, demandando uma proteção mais acentuada, que, invariavelmente, deságua na necessidade de negociação coletiva para que seja válida. É o que se extrai, inicialmente, das Convenções 168, e 122 da OIT.

O tema do direito internacional e da aplicação dos Tratados internacionais interessa à presente explanação por força do art. 5º, §§ 2º e 3º, CF (EC 45/2004). De efeito, os tratados internacionais sobre direitos humanos, de que são espécies as Convenções da OIT-Organização Internacional do Trabalho, quando observado o quórum qualificado, equivalem a normas **constitucionais**; e, mesmo quando não possuam este *status,* por eventual deficiência do quórum ou por serem anteriores à EC 45/2004, os tratados internacionais sobre direitos humanos (e, portanto, sociais ou,

mais especificamente, trabalhistas) são assinalados pela eficácia normativa da ***supralegalidade,*** vale dizer, são superiores à legislação ordinária nacional.

Logo, a presente matéria não pode ser analisada sem a devida incursão no plano das Convenções da OIT, ratificadas pelo Brasil, dada seu caráter de ***normas constitucionais*** ou de ***normas supralegais***.

A **Convenção 168** da OIT, com vigência interna a partir do Decreto nº 2.682 de 21 de julho de 1998, estabelece a "*Promoção do emprego e a proteção contra o desemprego*". Logo em sua justificativa, a Convenção afirma "*a importância do trabalho e do emprego produtivo em toda sociedade, em razão não só dos recursos que criam para a comunidade, mas também da renda que proporcionam aos trabalhadores, do papel social que lhes outorgam e do sentimento de satisfação pessoal que lhes infundem*".

Por meio de seu **artigo 2º**, determina-se que "*Todo membro deverá adotar **medidas apropriadas** para coordenar o seu **regime de proteção contra o desemprego** e a sua **politica de emprego**. Para esse fim, deverá **providenciar** que o seu **sistema de proteção contra o desemprego** e, em particular, as **modalidades de indenização do desemprego**, **contribuam para a promoção do pleno emprego produtivo**, livremente escolhido, e que não tenham como resultado dissuadir os empregadores de oferecerem emprego produtivo, nem os trabalhadores de procura-lo*". E ainda, no **art. 7º**, ordena que "*Todo Membro deverá formular, como **objetivo prioritário**, uma **política destinada a promover pleno emprego**, produtivo e livremente escolhido, por todos os meios adequados, inclusive a seguridade social. Esses meios deverão incluir, entre outros, os serviços de emprego e a formação e a orientação profissionais*".

É óbvio que o tema do *pleno emprego* se encontra intimamente relacionado com o das *dispensas coletivas,* haja vista que estas podem comprometer mortalmente a política social que a referida Convenção reclama dos países membros.

Nesse mesmo sentido é a **Convenção 122** da OIT, que estatui a "*Política de emprego*", ressaltando a importância da "*execução de programas de*

que resulte o pleno emprego e a elevação dos níveis de vida". Esse instrumento também se encontra vigente internamente, por meio do Decreto nº 66.499 de 27 de abril de 1970.

Logo em seu **artigo 1º**, estabelece: "*Com vista a estimular o crescimento e desenvolvimento econômico, elevar os níveis de vida, corresponder às necessidades de mão-de-obra e* ***resolver o problema do desemprego*** *e do subemprego, cada Membro deverá declarar e aplicar, como* ***objetivo essencial****, uma* ***política ativa com vista a promover o pleno emprego****, produtivo e livremente escolhido"*.

O Estado Brasileiro possui como objetivo prioritário a promoção do **pleno emprego** (art. 170, CF), situação que demanda medidas apropriadas para a proteção contra o desemprego. Esse compromisso internacional, ratificado internamente, não se coaduna com o acolhimento de uma despedida coletiva discricionária, que provoca, como já destacado, profundo impacto social, afetando todo um setor profissional. Logo, a dispensa coletiva, quando ocorra sem nenhuma política social pelo empregador ou sem negociação com as entidades sindicais, ofende, a um só tempo, a determinação constitucional da busca do pleno emprego e o fim social da propriedade empresarial, vale dizer, da **atividade econômica responsável**.

Nesse diapasão, a **única medida verdadeiramente eficaz** contra a dispensa coletiva, em consonância com o que se vem defendendo, é a exigência de negociação coletiva, uma vez que não é possível enrijecer os patamares e as condições da despedida, já que cada situação demanda uma solução diversa, ao passo que somente os sujeitos envolvidos poderão visualizar as consequências adequadas para cada uma das partes. Portanto, cabe ao sindicato da categoria, responsável constitucional por defender os interesses dos trabalhadores a ele vinculados, realizar discussões com a empresa em dificuldades econômicas, com o escopo de encontrar a devida medida capaz de "recuperar o fôlego" da companhia, causando o mínimo de impacto possível na sociedade.

A defesa da necessidade de **negociação coletiva** em caso de dispensa em massa, por sua vez, se coaduna com a importância assegurada pelo Estado Brasileiro a esse instituto por meio das Convenções 98 e 154 da OIT. Deveras, a negociação coletiva é a melhor forma de entendimento entre empregados e empregadores

para tratar de assuntos coletivos. O Estado reconhece tais negociações coletivas por meio do art. 7º, XXVI, CF *("reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho")*.

Desde o ano de 1949, data da ratificação (Decreto Legislativo 49) pelo Brasil da **Convenção 98 da OIT**, o "*direito de sindicalização e de negociação coletiva*" são reconhecidos no país.

Em seu **artigo 4º** a citada convenção determina que "*deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições nacionais para* ***fomentar*** *e promover o pleno desenvolvimento e* ***utilização*** *voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e* ***organizações de trabalhadores***". Entenda-se: ***fomentar*** significa "estimular", "incentivar", "propiciar" as negociações coletivas.

Na mesma linha é a **Convenção 154**, inserida no Ordenamento Interno por meio do Decreto Legislativo 1.256, em setembro de 1992, que, por sua vez, reafirma o "*incentivo à negociação coletiva*" e sua importância para o desenvolvimento da nação.

Extrai-se, do **artigo 5º** da mencionada convenção, em sintonia com o exposto, que "*deverão ser adotadas medidas adequadas às condições nacionais para* ***fomentar a negociação coletiva***". O artigo 4º, no mesmo sentido determina: "*na medida em que não se apliquem por meio de contratos coletivos, laudos arbitrais ou qualquer outro meio adequado à pratica nacional, as disposições da presente Convenção deverão ser aplicadas por meio da legislação nacional*".

Observa-se, destarte, que, no direito internacional, internamente aplicado conforme já demonstrado, a **negociação coletiva** não é apenas um dos vários meios de resolução dos conflitos sociais, mas sim o **único instrumento adequado** e eficaz para a obtenção de uma solução justa envolvendo uma coletividade de trabalhadores, motivo pelo qual o Estado Brasileiro firmou o compromisso de incentivar e de fomentar tal espécie de negociação.

A obrigatoriedade a que as partes sentem para dialogar sobre tema não caro à sociedade não implica compeli-las a concordarem entre si, vez que

ninguém é obrigado a negociar contra a própria vontade. Mas o estabelecimento do diálogo, considerando as repercussões da dispensa coletiva, pode perfeitamente ser exigido. Esta solução constitucional não é inócua, já que possibilitará o conhecimento sobre a realidade do setor e abrirá margem a que os trabalhadores, possam, por exemplo deflagrarem greve. É que o esgotamento da via negocial é requisito para a deflagração da paralisação coletiva (Lei nº 7.783/89, Lei de Greve). Possibilitará, também, que o sindicato adote outras providências, inclusive judiciais, pois estará ciente dos fatos e disporá de elementos hábeis ao ajuizamento das ações apropriadas. É inadmissível que o sindicato seja pego, da noite para o dia, com a notícia de uma dispensa coletiva, afetando sensivelmente sua base de representação, sem nenhuma outra informação, sem nenhum dado econômico, sem nenhuma chance de defender a categoria (art. 8º, IV, CF).

Por fim, aplicando tais conclusões às fronteiras do presente estudo, obtém-se a **dedução inexorável** de que é imprescindível a prévia negociação coletiva para que seja válida uma dispensa de caráter massivo, única meio eficaz de combater essa forma de desemprego, permanecendo o Estado na busca do pleno emprego.

VII.(c) INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO:

Dispõe o art. 477-A, CLT, *"as dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação".*

Caso não acolhida por essa Excelsa Suprema Corte a tese de inconstitucionalidade aqui levantada, é de se ver que o texto acima transcrito merece, no mínimo, ser interpretado para que se adeque ao Texto Constitucional.

Destarte, mesmo que se reconheça o caráter privado das relações contratuais de trabalho, assinaladas pelo princípio da autonomia privada, e que, por isso, as rescisões não dependam de autorização dos sindicatos ou de celebração de acordo ou convenção coletiva, o caso dos autos é diferente.

Dentro do princípio de valorização do diálogo social e da proeminência das negociações coletivas, cabe ao Estado estimular que empregados e empregadores dialoguem, especialmente perante situação tão grave e de dimensão tão grande quanto as dispensas em massa.

Então, é razoável e se adequa ao Texto Constitucional e às Convenções internacionais do Trabalho ns. 98, 122, 154 e 168, que se entenda que as partes coletivas não estão obrigadas a celebrar acordo ou convenção, mas devem estabelecer tratativas procedimentais pelas quais **tentem** chegar a consensos sobre pontos que possam facilitar a rescisão dos contratos individuais, minimizar o impacto social e estabelecer outras regras de interesse de trabalhadores e empregadores. Ninguém é obrigado a negociar; mas, no plano das relações coletivas, comete conduta antissindical a parte que se recusa a, pelo menos, dialogar com a outra. Portanto, o estabelecimento de canal negocial prévio é requisito para a dispensa em massa.

VIII. DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO NO QUE CONCERNE AOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS:

Como se sabe, é expressamente vedado o retrocesso em matéria de direitos humanos fundamentais, dentre os quais se enquadram os apontados no início dessa exordial, violados, com veemência, pelos atos impugnados.

Nesse contexto, na linha dos ensinamentos de Flavia Piovesan, perita no assunto, *in verbis*, não há como deixar de declarar, cautelar e definitivamente, a inconstitucionalidade dos atos impugnados:

> "Da obrigação da progressividade da implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais decorre a chamada cláusula de proibição do retrocesso social, na medida em que é vedado aos Estados retroceder no campo da implementação desses direitos. Vale dizer, a progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais proíbe o retrocesso ou a redução de políticas públicas

voltadas à garantia de tais direitos cabendo ao Estado o ônus da prova. Isto é, em face do princípio da inversão do ônus da prova, deve o Estado comprovar que todas as medidas necessárias – utilizando o máximo de recursos disponíveis - têm sido adotadas no sentido de progressivamente implementar os direitos econômicos sociais e culturais enunciados no Pacto." **(Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 12ª ed., 2011, p. 235)**.

IX. DOS REQUERIMENTOS NECESSÁRIOS:

Por todo o exposto, requer-se:

(a) Cautelarmente, em caráter de urgência, seja concedida, de imediato, pelo relator que vier a ser designado, medida liminar determinando a suspensão da eficácia dos atos impugnados; e

(b) que nos termos do art. 10 da Lei n.º 9.868/99, após a manifestação do Presidente da República e do Congresso Nacional, que deverão se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido cautelar, seja referendada pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal a medida cautelar liminarmente concedida pelo relator;

(c) que se peçam informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, órgãos dos quais emanaram os atos impugnados, bem assim de outros órgãos ou entidades que contribuam para o feito no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 6º e 7º, §2º, da Lei 9.868/1999);

(d) que sejam ouvidos o Advogado Geral da União e a Procuradora Geral da República, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 8º da Lei 9.868/1999); e

(e) definitivamente, após o regular processamento da ação, que seja declarada a inconstitucionalidade, com efeitos *ex-tunc*, dos atos impugnados (art. 477-A, e art. 855, §§ 1º, ambos da CLT).

(f) Sucessivamente, que essa Excelsa Corte confira **interpretação conforme à Constituição**, para esclarecer que as despedidas em massa devam ser submetidas previamente a diálogo ou negociação com a entidade sindical que represente os trabalhadores, nos termos da orientação constante das Convenções internacionais citadas nesta peça processual.

Valora-se a causa em R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.

Termos em que pede deferimento.

Brasília, 20 de maio de 2019.

CARLOS GONÇALVES JÚNIOR
OAB/SP Nº 183.311

LUÍS FELIPE PARDI
OAB/SP Nº 409.236

MIGUEL ÂNGELO SALLES MANENTE
OAB/SP Nº 113.353